

1512541-02.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... na esfera criminal".

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512541-02.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512541-02.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2220166/2021 -

DEL.INV.GER. AMERICANA, 19611656 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 1006/21/350 -

DEL.INV.GER. AMERICANA, 2220166 - DEL.INV.GER. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LUCA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

MATHEUS LUCA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei 8069/90, em concurso material de delitos, porque na data e locais descritos na denúncia, previamente conluiado e com unidade de propósito o adolescente G.H., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra M.D.S.B., subtraiu para o proveito comum, coisa alheia móvel, ou seja, o automóvel CHEVROLET/Onix, placas GGR-0370, documentos pessoais, cartões bancários, um aparelho de telefonia celular marca "MOTOROLA", e a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima. Consta, finalmente, que

corrompeu menor de dezoito anos, com ele praticando infrações penais. A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2021 (fls. 70/72), momento em que foi decretada a prisão preventiva.

O réu foi citado (fls. 113), apresentando defesa (fls. 119/121 e 149/151).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 131/132 e fls. 180/181).

Foram apresentadas as respostas (fls. 240 e 241) e laudo de fls. 245/267 e 268/287.

Encerrada a instrução (fls. 289), em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 352/355), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a consequente condenação.

Em suas alegações finais, a Doutora Defensora do réu (fls. 359/365), requereu a absolvição pela falta de provas.

Ante a apresentação de matéria preliminar, os autos retornaram ao Ministério Público, o qual manifestou-se (fls. 371).

É, em síntese, o relatório.
DECIDO.

Preliminarmente, considerando a informação de fls. 241, para evitar-se tumulto processual a investigação para determinar-se a eventual participação da pessoa de Douglas, em delitos perpetrados, deverá ser efetuada em Inquérito apartado.

No mais, nada a prover acerca do pedido de complementação de prova pericial para a verificação da localidade do celular do réu. Inicialmente, verifica-se que a prisão não foi em flagrante, e desta forma, é impossível precisar se o celular encontrava-se em sua posse no momento do delito.

No mérito, a ação penal é procedente.

Roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima.

A doutrina distingue duas espécies de roubo: roubo próprio, no qual a violência ou a grave ameaça é exercida antes da subtração da coisa, ou seja, a violência ou grave ameaça é exercida para que o agente subtraia a coisa material e ainda o roubo impróprio, quando o agente emprega a violência contra a pessoa ou a grave ameaça logo após subtraída a coisa.

O roubo próprio se encontra capitulado no "caput" do artigo 157 do Código Penal, e o roubo impróprio se encontra capitulado no parágrafo 1º do mesmo artigo.

Sobre o momento da consumação do delito de roubo, decidiu a 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com voto magistralmente relatado pelo eminente Desembargador Souza Nery, que este se dá no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente consegue retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo, estando portanto já consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo, independentemente do que venha a ocorrer na sequência, ou seja, do grau de impertubabilidade da posse da res, da existência ou não de perseguição ou de sua intensidade, etc. (Apelação Criminal 990.09.067051-7, j. 13.08.2009).

Nesse sentido, o entendimento do STF:

"... o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência da posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do esforço imediato - seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão." (RE nº 102.490-9/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in RT 677/428).

A materialidade do delito de roubo se encontra comprovada pelos autos de fls. 03/05, 13/15 e 33.

A autoria é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu Matheus negou a prática do delito. Alegou que estava na casa da irmã e do cunhado Mateus, tendo pernoitado no local. Narrou que em uma "blitz" o policial tirou sua foto, e acredita que a vítima reconheceu essa foto. Confirmou conhecer o adolescente.

Em audiência, a vítima, relatou o ocorrido.

A vítima M.D.S.B., ouvida em Juízo, informou que trabalha como motorista de aplicativo, sendo que a corrida foi solicitada por alguém que se chamava Luciana. No local, apareceram dois indivíduos do sexo masculino, alegando que quem chamou a foi uma amiga. Informou que o réu estava do lado do passageiro e o menor no banco de trás. Durante o trajeto, o menor deu um "mata leão" no pescoço da depoente, e o réu apontou um arma, e levaram o veículo e objetos. Disse, ainda, que pediu ajuda a terceiros e acionou a polícia. Por fim, reconheceu o réu como o autor do delito, sendo ele quem portava a arma de fogo.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente'

(JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois,

incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320). No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354.(CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

"(...) MÉRITO ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. (...)". (TJSP, Apl. Crim.0002294-84.2017.8.26.0210, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.02.2020).

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação"(TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (JUTACrim 94/341).

O Investigador de Polícia Ricardo informou que receberam a notícia acerca do crime, e entraram em contato com a vítima, a qual relatou os fatos, ou seja, a chamada pelo aplicativo "Uber", pela pessoa de "Luciana", sendo que no local, adentraram o veículo dois indivíduos e que no final do trajeto, eles efetuaram o roubo. Narrou que apresentaram a vítima fotografias de suspeitos de roubo de "Uber" na região, e ela reconheceu o réu e o menor. Após a prisão temporária, a vítima fez o reconhecimento pessoal. Informou que foram sete ou oito roubos semelhantes na região, sendo que o a vítima sempre era imobilizada por traz, e outro indivíduo apontava algo, em alguns há relatos de arma de fogo. Em cumprimento de mandado de busca na casa de Luciana, foi apreendido um celular, verificando-se ocorrência de outras chamadas em outros delitos. Narrou que durante a investigação, o réu e o menor foram considerados suspeitos em outros delitos semelhantes. Por fim, a vítima foi muito segura no reconhecimento fotográfico.

E, o Investigador de Polícia Tiago informou que participou como apoio das investigações onde a vítima, reconheceu o réu e o adolescente como autores do roubo. Narrou, ainda, a existência de outros delitos semelhantes, partindo do mesmo endereço. Por fim, durante a prisão do réu não foi localizada qualquer arma.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência

nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência: Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – Condenação mantida Penas corretamente fixadas – Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

Por fim, as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos.

Ainda, a testemunha Mateus disse que no dia 23 de julho de 2021, por volta das 20h30min, estava em sua casa, acompanhado do réu e de Patrik, sendo que estavam lixando a parede, para posterior pintura. Declarou que o réu dormiu em sua casa neste dia. Narrou que filmaram um vídeo nesse dia, mas o réu não aparece. Por fim, apenas após o assalto, foram recordar onde estavam dia 23.

E a testemunha Patrik disse que das 18h até as 22h, estava na casa do Mateus, ajudando a pintar a casa. Declarou que o réu também estava no lugar.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Em que pese a defesa apresentada, não é possível a absolvição, considerando a ameaça efetuada pelo réu, em concurso com o menor, inclusive com utilização de arma de fogo, ao proceder a subtração do bem, restando configurado o roubo qualificado. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL. Condenação mantida. Réus confessos. Palavras do ofendido e de testemunha presencial. Desclassificação para furto afastada. Grave ameaça comprovada pela simulação do porte de arma. Crime consumado. Inversão da posse. STJ, Súmula nº 582. Penas mantidas. Maus antecedentes comprovados. Concurso formal caracterizado. Regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500056-43.2018.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Pela mesma razão, não há que se falar em menor importância das ações, posto que o agente que contribuiu ativamente para a realização do crime, não podendo ter sua conduta classificada como de menor importância.

Apelação criminal. Roubo. Concurso de agentes. Autoria. Participação. Menor importância. É de autoria concursiva, e não de simples participação? Menos ainda e menor importância? a conduta da pessoa que executa, em conjunto com as demais, o núcleo típico consistente em subtrair a coisa da vítima, ainda que não a rendendo frontalmente. (TJSP; Apelação Criminal 0054873-04.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 06/11/2018)

Ainda, não é possível o reconhecimento da desclassificação para o delito para furto, considerando a violência e ameaça perpetradas.

ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firme e segura de que sofreu grave ameaça, correta a imputação pelo crime de roubo. COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO - REGIME PRISIONAL ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500638-48.2019.8.26.0533; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES E SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - Não cabimento: Bem demonstrada a abordagem efetuada por três indivíduos que, simulando o porte de armas, arrancaram a bolsa do braço da vítima e, portanto, presentes a grave ameaça e violência, impossível falar-se em desclassificação. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007125-34.2009.8.26.0477; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2010; Data de Registro: 09/09/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL. Condenação mantida. Réus confessos. Palavras do ofendido e de testemunha presencial. Desclassificação para furto afastada. Grave ameaça comprovada pela simulação do porte de arma. Crime consumado. Inversão da posse. STJ, Súmula nº 582. Penas mantidas. Maus antecedentes comprovados. Concurso formal caracterizado. Regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500056-43.2018.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Relativo à qualificação (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), provada pelas testemunhas a existência da arma de fogo, não pode a qualificadora ser afastada pela simples falta de sua apreensão em poder do réu. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, além de corrupção de menores, praticados em concurso formal e material. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que não se insurgiu contra o encerramento da instrução criminal no momento oportuno. Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria dos delitos. Crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Delito formal. Comprovado o envolvimento de adolescente nas infrações penais praticadas pelos réus. Pretensão de afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas declarações das vítimas. Arma de fogo que possui potencial lesivo inerente à sua natureza. Condenação mantida. Dosimetria penal. Viável a redução da pena-base relativa ao corréu Leandro. Cabível o reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os crimes de roubo. Aumento decorrente do concurso formal por violação a patrimônios jurídicos distintos afastado, a fim de evitar bis in idem. Precedentes do STJ. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado mantido em razão do quantum das penas e da gravidade concreta dos delitos. Recursos parcialmente providos (TJSP - Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

APELAÇÃO. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da causa de aumento. Prova técnica substituída pela oral. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Reconhecimento de duas causas de aumento, uma das quais foi considerada como circunstância judicial. Alegação de imposição de dois aumentos sucessivos. Dosimetria mais benéfica. Ausência de modificação da quantidade de pena. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Criminal 1500108-23.2018.8.26.0616; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Apelação. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso formal. Sentença condenatória. Recursos das defesas. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento pessoal dos acusados. Relatos dos investigadores de polícia. Emprego de arma demonstrado. Desnecessidade de apreensão e perícia. Prova oral que indica a presença da causa de aumento. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias e consequências do delito. Roubo ocorrido em estabelecimento comercial com pluralidade de vítimas e bens subtraídos. Reconhecimento do concurso formal. Bis in idem configurado. Regime fechado mantido. Manutenção da custódia cautelar. Recurso provido para readequar as penas impostas. (TJSP - Apelação Criminal 1502946-56.2018.8.26.0577; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

ROUBO - Emprego de arma - Ausência de apreensão - Reconhecimento da qualificadora - Possibilidade.59 - A ausência de apreensão da arma empregada pelo agente quando da prática de roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial. RJDTACRIM VOLUME 10 ABRIL/JUNHO 1991
PÁGINA:117 RELATOR: GONZAGA FRANCESCHINI

ROUBO - Emprego de arma - Ausência de apreensão - Testemunho da vítima - Suficiência - Qualificadora - Configuração.74b - O testemunho da vítima e suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão. RJDTACRIM VOLUME 10 ABRIL/JUNHO 1991 PÁGINA:142
RELATOR:-MARREY NETO

Desta forma, o conjunto probatório, inclusive o reconhecimento da vítima em juízo, confirma a prática do delito de roubo qualificado pelo concurso com o menor e, ainda, pela utilização de arma de fogo, não sendo passível de acolhimento do pedido da defesa para a absolvição por falta de provas.

As testemunhas de defesa, em que pese alegarem a presença do réu em local diverso (fls. 176), não o comprovaram, posto que o réu não aparece nos vídeos. É notório que no caso de invocação de alibi, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte que alegou demonstra-lo.

A declaração de fls. 241, também não isenta o réu da participação, sendo passível de verificação apenas o envolvimento de outras pessoas nas ações delituosas, tendo em vista que, conforme informação policial, diversos delitos semelhantes foram cometidos, com início da solicitação pelo mesmo usuário.

Há que se analisar, ainda, que as conversas do aparelho celular do réu (laudo de fls. 245/267) indicam sua participação em delitos, inclusive de subtração de veículos, enquanto era adolescente. E, também, sua ligação com o adolescente G.H. (fls. 278/279).

Por fim, também ficou demonstrada a participação do menor na prática dos delitos. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. Com a decisão, os ministros consolidaram o entendimento de que, para a caracterização do delito, é suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos. STJ, Súmula 500: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Precedentes da 5ª e da 6ª Turma do STJ estabelecem ainda que a caracterização do crime independe de o menor ser primário ou já ter cumprido medida socioeducativa.

Essa conclusão foi destacada em um dos precedentes da súmula, o Habeas Corpus (HC) 150.849, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. "A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação", concluiu o ministro.

Em outro precedente, o Recurso Especial 1.127.954, relatado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, destacou-se que, "ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal". RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF (DJe 1º/2/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. [...] 7. Recurso especial não provido. (Resp 1.501.842/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 18/4/2016)

"[...] Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou

facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.[...]" (REsp 1112326 DF, submetido ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 08/02/2012)

"[...] Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.[...]" (REsp 1127954 DF, submetido ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 01/02/2012

"[...] 'Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.' [...]" (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

"[...] a corrupção de menores é delito formal, não sendo necessária prova de efetivo desvirtuamento do inimputável. Outrossim, é descabido o argumento de que o menor já seria corrompido, porquanto o comportamento do réu, consistente em oportunizar, ao inimputável, nova participação em fato delituoso, deve ser igualmente punido, tendo em vista que implica em afastar o menor, cada vez mais, da possibilidade de recuperação.[...]" (AgRg no REsp 1371397 DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 17/06/2013)

"[...] Para a configuração do delito de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação de menor de 18 anos em crime na companhia de agente imputável [...]" (HC 182805 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Restou comprovado nos autos que o réu, com o menor, praticaram o delito de roubo.

O conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu Matheus, previamente ajustado ao menor, e em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu os pertences da vítima.

Desta forma, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

O réu, na época dos fatos, era tecnicamente primário. Assim sendo, para o delito de roubo, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, é impossível a consideração da circunstância atenuante (art. 65, inc. I, do CP), tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo. A questão foi abordada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que lança uma pá de cal sobre a matéria: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ainda, conhecidas as causas de aumento, ensejando o roubo qualificado, por força do que dispõe o § 2º, inciso II, e do §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes e arma de fogo), e no termos do § único, do art. 68, do CP, excepcionalmente, neste caso, tendo em vista a ausência circunstâncias concretas a

fundamentar a opção mais gravosa (duplo acréscimo 1/3 e 2/3), acresço as penas em apenas 2/3 (dois terços), fixando a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Relativo ao artigo 244-B, "caput", da Lei 8069/90, fixo em 01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menores, sendo impossível a consideração de qualquer circunstância atenuante, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo.

Verifica-se a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, somadas as penas perfazem um total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O dia-multa é fixado no piso.

Regime de cumprimento da pena.

Superada a fixação da pena, com os fundamentos legais já expostos, de rigor a estipulação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, como exigido pelo artigo 59, inciso III do Código Penal.

Além da gravidade, só por si, o crime, que está num crescente assustador, colocando em polvorosa a comunidade ordeira de Americana, suas seqüelas para as vítimas, que prestaram depoimento na ausência dos réus, certamente atemorizadas ainda pelos fatos. A própria legislação atual, considerando a violência e a grave ameaça embutida no tipo, veda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Além disso, o réu não provou desenvolver qualquer atividade lícita.

Não é por outro motivo que o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, na maioria de suas Câmaras e distinguindo corretamente as exigências para a fixação da pena e de regime, vinha elegendo o fechado como regra em se tratando de crime de roubo. Nestes autos, volto a anotar, circunstância alguma recomenda fixação de regime mais brando.

Assim o entendimento da doutrina:

"...pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito, que, no caso, vêm causando grande comoção social (MIRABETE, Julio Fabbrini, Execução Penal, 8a ed., Atlas, 1997, p. 255, texto e nota 6)".

"Não se pode porém olvidar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-seá com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, consoante dispõe seu art. 33, § 3º.

Desse modo, num roubo, com emprego de arma, cometido por réu primário, ainda que a pena concreta não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, o juiz poderá determinar o cumprimento da pena em regime fechado. (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", Ed. Oliveira Mendes-APAMAGIS, 1997, p. 8)

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

ROUBO MAJORADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante concurso de agentes, de rigor a manutenção do édito condenatório. REGIME PRISIONAL - CRIME GRAVE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa

de liberdade e da primariedade do réu. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1530412-93.2018.8.26.0037; Relator: Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Com efeito, não é possível constatar flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois, embora a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a exemplo dos maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de execução mostra-se adequado na espécie. [...] 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 326.343/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 25/11/2015)

ROUBO - Regime Prisional Fechado - Necessidade Indeclinável - "É de primeira evidência que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que regem a convivência social. Pelo que, deve o Juiz sujeitar quem o pratica ao mais severo regime prisional. Demais, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a periculosidade do condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, haja vista que subordina a concessão do livramento condicional a exame criminológico elidente, scilicet, atestatório da cessação da potencialidade recidivista" (TACRIM_SP - Ap. nº 1.004.065/3 - São Paulo - 7ª Cam. - Rel. Juiz CORRÊA DE MORAES, j. 13.3.97, v.u.)

REGIME PRISIONAL - Fechado - Substituição pelo regime semiberto - Réu primário - Inadmissibilidade - Determinação do regime inicial que se faz com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal - Hipótese em que o crime de roubo evidencia a periculosidade do agente - Sentença confirmada - Recurso não provido. (Relator: Nelson Fonseca - Apelação Criminal n. 167.440-3 - São Paulo - 15.09.94)

A esse respeito, julgando recurso deste juízo, o Eminentíssimo Magistrado Corrêa de Moraes, com muita propriedade assevera que a fixação de outro regime que não o fechado nos casos de roubo qualificado significa não apenas abrir uma porta para a impunidade, mas rasgar a via larga da impunidade, e chega a afirmar que a fixação de outro regime é crime de lesa-sociedade. Cumpre, pela pertinência, transcrever o V. Acórdão, brilhantemente relatado:

"Em se tratando de roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e suficiência (C.P., art. 59).

Esta Colenda Câmara tem proclamado, vezes sem conta, que o regime fechado é o único compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais intranquilizadoras expressões da criminalidade, nos tempos correntes.

Vem de molde observar que inexistente relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e a determinação do regime prisional, seguro que esta será feita com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal (cf. § 3º do art. 33).

Sobre o tema, cabe invocar o seguinte ensinamento do STF:

"A determinação do regime inicial de cumprimento de pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Código Penal, mas, também de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E

deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59"(HABEAS-CORPUS nº 70.289 - SP - Primeira Turma p Rel. Min. Sydney Sanches, in RTJ 148/490).

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional (CP, artigo 59, III).

Aliás, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a periculosidade do "condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa", haja vista que subordina a concessão de livramento condicional a exame criminológico elidente, ou, por outras palavras, atestatório da cessação da potencialidade recidivista (CP, parágrafo único do art. 83).

A orientação desta Câmara inspira-se na enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 65.501-SP, verbis;

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias". (cf. R.T.J. 123/457)

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário" (Habeas Corpus nº 74.301-3, de São Paulo, DJU 6.12.96, pág. 48.711).

Acresce ponderar que a concessão de regime semi-aberto ao autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa..

Anote-se, por último, que, a prevalecer o entendimento pelo qual a determinação do regime prisional é corolário imperativo da quantidade da pena reclusiva aplicada, seria obrigatório, em linha de coerência, aquinhoar o autor de roubo simples com o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, "c"). A impropriedade, inconveniência e injustiça de tal posição saltam aos olhos.

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do código Penal, força é convir que o agente de roubo sujeita-se ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência "personalidade" marcadamente defeituosa (cf., exemplificativamente, ac. un. na ap. nº 673.255/1 de São Paulo).

Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo"(JUTACRIM 88/870. Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

Sem embargo, não falta que, escudado no pretexto da inadequação do sistema carcerário, entenda compatível com o interesse público a manutenção de assaltante em regime aberto, sob a forma domiciliar.

Ora, tangencia a mais cândida ingenuidade supor que perigoso assaltante irá observar escrupulosamente as regras do regime aberto, muito especialmente as

relativas ao recolhimento “durante o período noturno e nos dias de folga”...

Conceder regime aberto (e até mesmo o intermediário) a autor de roubo não significa apenas abrir uma porta para a impunidade, mas, em verdade, rasgar a via larga da reincidência. Provam-no as alarmantes estatísticas sobre fugas dos institutos penais agrícolas e sobre a execução de crimes por supostos reclusos em tal sistema. Em poucas palavras: regime outro que não o fechado para assaltante é crime de lesa-sociedade. Regime aberto para rapinante tem o odor, o sabor e a cor de escandalosa impunidade.” (os grifos constam do original) (Apelação nº 1.083.043/1, de Americana)

Em julgado, também de recurso contra decisão proferida por este juízo, assim decidiu a 5ª Câmara da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“...o regime inicial fechado para desconto da corporal deve ser mantido, pois a infração penal praticada com emprego de arma e concurso de agentes, revela temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos agentes, a justificar início de regime mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência dos artigos 33, § 3º c.c. art. 59, ambos do Código Penal). (Apelação Criminal nº 00485355.3/1-0000-000, Relator, Desembargador Marcos Zanuzzi, 21 de setembro de 2006).

Apesar do réu ser tecnicamente primário, não pode apelar em liberdade, porquanto a gravidade do crime, e o modus operandi devem influenciar na concessão da liberdade para recorrer, e em se tratando de roubo praticado mediante grave ameaça, salvo prova excepcional em contrário, a regra é a prisão provisória do réu.

Assim é o entendimento de jurisprudência, conforme o V. Acórdão que segue, brilhantemente relatado pelo eminente Magistrado Haroldo Pinto da Luz Sobrinho: “O conceito amplo de bons antecedentes, como requisito da liberdade para apelar, compreende, além dos episódios da vida pretérita do réu, as circunstâncias em que praticou o delito tratado na sentença cujo reexame pretende em grau de apelação” (HC - 218.978/1 - TACRIM_SP - 2ª Câmara - Rel. Haroldo Luz - RJDTACRIM 13/196)

E, ainda:

Habeas Corpus - Condenação por roubo majorado - Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência - Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal - Situação fática inalterada - Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2218120-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Juiz sentenciante, conforme o art. 387, § 1º, do CPP, ao concluir pela necessidade da decretação da custódia cautelar ante a periculosidade do paciente,

evidenciada pela gravidade concreta do delito - roubo praticado com arma de fogo e concurso de agentes, em um restaurante - e pelas condições pessoais desfavoráveis do réu, decidiu conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior. Ficou consignado, ainda, que o réu possui condenações penais anteriores por crimes patrimoniais, o que denota sua reiteração delitativa. 3. (...). 4. Ordem denegada. (HC 497.109/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

Ademais, o réu encontra-se preso por força de prisão preventiva, e segundo a melhor doutrina, e jurisprudência majoritária, o dispositivo é inaplicável no caso de réu preso provisoriamente.

Segundo o ilustre penalista Damásio Evangelista de Jesus:

"Segundo o entendimento pacífico do STF, essa disposição é inaplicável a réu preso em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que e/a visa apenas abrandar o princípio da necessidade de e/e recolher-se à prisão para apelar (RHC 54.430, DJU 26.11.76, p. 10203). Assim, réu que por ocasião de sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459, RHC 56.953, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Sobre o assunto, decidiu o TJSP que " Lei n. 5.941, de 1973, é de interpretação restrita. Não nulificou a prisão em flagrante delito, cuja permanência no sistema processual vigente, vai até a sentença. Se esta for absolutória, o réu será posto em liberdade. Se for condenatória, aquela permanência se prolonga, porque um dos seus efeitos (art. 393, I) é ser o condenado conservado na prisão. Se for de pronúncia, só então o magistrado deverá reexaminar a custódia provisória, para revogá-la caso satisfaça o agente os requisitos legais", (RT- 500/318). No mesmo sentido: RT 531/295 e RTJ 88/69; RHC 57.947, DJU 13.6.80, p. 4461, e RHC 58.053, DJU 12.8.80, p. 5786. E, se a acusação apela visando à agravação da reprimenda, o réu permanece detido, ainda que já tenha cumprido o quantum da pena imposta na sentença condenatória (Código de Processo Penal Anotado - Direito Informatizado Saraiva - 1ª Edição em CD-ROM - 1995).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"É que o paciente respondeu o processo preso cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevivendo sentença condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os atributos elencados pelo ilustre impetrante. Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Na espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As condições pessoais favoráveis não são requisitos bastantes para a concessão de liberdade provisória, e, ademais, no caso dos autos, o paciente não logrou demonstrar ocupação lícita e possuir residência no distrito da culpa. 4. Habeas corpus denegado." (HC nº 207.906/RJ, Quinta Turma